

1501778-71.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... criminais pela prática do crime de tráfico em outro estado da Federação e que iriam entregar aquelas porções de drogas para um indivíduo desconhecido.

A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a variedade e as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes.

Foram arroladas duas testemunhas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501778-71.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501778-71.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER TOBIA MASTROMORO BERTO e outro

CONCLUSÃO:

Aos 26 de novembro de 2021, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MMA. Juíza de Direito. Escrev.:.

Autos digitais controle nº 1524/2020:

Vistos,

WAGNER TOBIA MASTROMORO BERTO e MARCELA FERREIRA DOS SANTOS, qualificados às fls. 21 e 29, respectivamente, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 17h00, na Rua Joaquim Mascaranha, 17, Bairro Dos Finco, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, traziam com eles e transportavam, para fins de venda, substâncias entorpecentes, consistentes em 20 porções de Cannabis Sativa L, contendo 70,98g, substância vulgarmente conhecida como maconha, 30 porções de cocaína, contendo 15,69g de cocaína, 49 porções de crack, contendo 23,17g e também 10 tubos de lança-perfume, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 14/16.

Segundo o apurado, policiais militares encontravam se em patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado WAGNER TOBIA MASTROMORO BERTO parado em uma esquina. Diante do nervosismo do denunciado ao avistar a viatura policial, os agentes da lei realizaram o retorno, ocasião em que ele passou a caminhar em direção a um veículo

que estava estacionado.

Nesse momento, diante das fundadas suspeitas, decidiram realizar a abordagem.

Em revista pessoal, em princípio, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado. Ato contínuo, ao ser indagado pelos policiais se havia outra pessoa no interior do veículo, o denunciado respondeu estar acompanhado de sua esposa, a denunciada MARCELA FERREIRA DOS SANTOS.

Neste instante, o denunciado WAGNER abriu a porta do veículo e pediu que a denunciada MARCELA descesse do veículo.

Os policiais militares perguntaram, dessa vez, se havia algo de ilícito no interior do veículo, ocasião em que o denunciado Wagner disse que havia drogas, sendo certo que a denunciada MARCELA especificou o local onde se encontravam, a saber em um pochete que estava no assoalho do seu banco.

Diante disso, os agentes da lei encontraram 49 porções de crack, 20 porções de maconha, 30 porções de cocaína e 10 tubos de lança-perfume.

Consigne-se que os denunciados afirmaram aos policiais que possuíam antecedentes criminais pela prática do crime de tráfico em outro estado da Federação e que iriam entregar aquelas porções de drogas para um indivíduo desconhecido.

A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a variedade e as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes.

Foram arroladas duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 05/77.

A decisão que concedeu a liberdade provisória se encontra às fls.58/60.

A decisão de fls. 90/91 determinou a notificação dos denunciados.

Laudos foram encartados aos autos, a saber: de exame químico toxicológico: fls. 122/124 (maconha e cocaína) e 144/146 (lança perfume).

Folhas de antecedentes de Minas Gerais acham-se juntadas a fls.120 (Wagner) e fls.121 (Marcela). Folhas de antecedentes de São Paulo encontram-se juntadas a fls.139 (Marcela) e fls. 140 (Wagner). Folhas de antecedentes federais acham-se juntadas a fls.141/142. Certidão em nome de Wagner foi juntada a fls. 153/158 (Mato Grosso do Sul).

WAGNER TOBIA MASTROMORO BERTO, regularmente notificado dos termos da inicial em 25.11.2020 (fls.149), ofertou defesa por meio da Defensoria Pública (fls. 167).

MARCELA FERREIRA DOS SANTOS, regularmente notificada dos termos da inicial em 25.11.2020 (fl.152), ofertou defesa por meio da Defensoria Pública (fls. 167)

A denúncia foi recebida pela decisão de fls.168/170, em 08.02.2021, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Os réus foram pessoalmente citados e intimados (fls. 188 - Wagner), tendo atendido ao chamamento judicial, comparecendo em audiência, de modo que se deu por citada. Realizada a audiência, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram qualificados e interrogados. Houve debates orais. O Ministério Público sustentou pedido de condenação dos réus nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa requereu a absolvição dos réus, alegando insuficiência probatória.

Alternativamente, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, assim como outras benesses legais (fls. 192/200).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo auto de apreensão de fls.14/15 (veículo, drogas e lança perfume), assim como pela juntada dos laudos de fls.18/20 (constatação), fls.144/146 (exame químico toxicológico do lança perfume) e fls.122/124 (exame químico toxicológico, maconha cocaína e crack ).

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

Os réus, ouvidos na fase inquisitorial, optaram por permanecerem em silêncio (fls.08/09).

Ouvida em Juízo, a ré Marcela informou que o marido desceu do carro para cobrar um amigo dele, avistou a viatura e foi abordado. Abriram o carro, ela desceu e, após revista, foram encontradas drogas no veículo, pois ele tinha feito uma corrida (o réu trabalha com aplicativo de transporte) para um conhecido dele chamado Beto,

tendo sido ele quem havia deixado as drogas no veículo. Disse que quando o Beto desceu, imaginou que ele tivesse levado as drogas. Só souberam que ele estava com entorpecentes durante a corrida, de modo que as drogas encontradas pelos policiais não eram deles. Disse estar desempregada, sendo que, na época, o marido e corréu fazia transporte por aplicativo. Não soube explicar porque o carro estava em nome de uma locadora. Disse que vivia com o Wagner há 8 (oito) meses quando foram presos e sabia que ele respondia processo por tráfico de drgas. Disse que quando ele fazia corridas pelo aplicativo para particulares, ela costumava ir junto. Esclareceu que Beto, suposto proprietário das drogas, estava com eles dentro do carro, mas desceu e deixou a pochete no banco de trás. Porém, os policiais na hora em que revistaram o carro encontraram os entorpecentes (gravação audiovisual no SAJ, fls.200). Em Juízo, o réu Wagner informou que não foi abordado na rua. Afirmou que os policiais o viram na esquina na companhia de outro rapaz, sendo que depois de conversar com ele, foi em direção ao seu veículo. Disse que os policiais o entrevistaram e revistaram o veículo, sendo que os entorpecentes foram encontrados debaixo do banco. Disse que foi fazer uma corrida particular, pois estava com a habilitação vencida, sendo que fez o transporte de um conhecido de nome Beto. Disse que o Beto correu quando viu a viatura. Afirmou que não foi ouvido na Delegacia. Esclareceu que tinha como atividade dar aulas de judô em duas escolas no Riacho Grande. Anteriormente foi preso com 13 quilos de drogas, mas ainda não foi sentenciado, afirmando que "foi uma outra burrada". Disse que conhecia os policiais que prestaram depoimento, porque sempre é abordado por eles. Disse que o veículo foi comprado pela mãe dele, mas era ele quem o dirigia (gravação audiovisual no SAJ, fls.200).

A testemunha André Luiz Silva, policial militar, narrou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram Wagner parado em uma esquina. Afirmou que quando ele viu a viatura policial, demonstrou nervosismo. Feita a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Como ele estava próximo de um veículo, foi perguntado se havia alguém dentro do carro e ele disse que sua esposa lá estava. Ele pediu para que ela descesse. A mulher estava sentada no passageiro e quando indagado se havia algo de ilícito no veículo, ambos disseram que havia drogas. Feita a revista, embaixo do banco onde a mulher estava sentada encontraram os entorpecentes (maconha, cocaína, crack e lança perfume) prontos para consumo. Eles disseram que iriam entregar as drogas nesse ponto de venda para uma outra pessoa. Eles estavam numa travessa de uma das ruas principais do bairro Riacho Grande. Quanto ao veículo, o réu disse que era da propriedade dele. Não falou quem tinha lhe fornecido a droga (gravação audiovisual no SAJ, fls.200).

A testemunha William Oliveira do Nascimento, policial militar, narrou que em patrulhamento de rotina, avistaram o réu em uma esquina, o qual ao ver a viatura ficou assustado. Então, fizeram a abordagem no momento em que ele se encaminhava para um veículo próximo. Feita a abordagem, nada de ilícito com ele foi encontrado. Ele disse que no veículo estava sua esposa. Ele próprio pediu que ela descesse. A mulher estava sentada no banco do passageiro. Foi perguntado se tinha alguma coisa de ilícito no veículo, sendo que a ré mostrou onde estavam as drogas. Elas se encontravam dentro de uma pochete no assoalho do banco onde ela estava sentada. Foram localizadas porções de cocaína, maconha e crack em uma quantidade razoável de cada uma, além de tubos de lança perfume, drogas as quais eles disseram que iriam entregar à um desconhecido, mas não disseram o nome. Chegaram a perguntar se eles tinham passagem, tendo eles afirmado que tinham passagem por tráfico de drogas em outro Estado. Quanto ao veículo, o réu disse que era dele, mas na Delegacia foi verificado que estava em nome da mãe dele. Informou que a rua em que eles estavam fica bem no centro do Riacho Grande (gravação audiovisual no SAJ, fls.200).

Assim, como se vê, as provas colhidas no decorrer da instrução autorizam a condenação dos réus. É certo que os depoimentos dos policiais demonstram que a acusação tal qual colocada na denúncia espelha o que de fato ocorreu naquele dia. E, no caso, os depoimentos dos policiais não podem ser afastados, seja porque eles não conheciam os réus, seja porque não estão impedidos de depor, de modo que não haveria qualquer motivo para que falsamente mudassem a versão dos acontecimentos para prejudicar quem quer que seja.

Não custa relembrar o quanto decide a jurisprudência acerca da validade do depoimento dos policiais:

“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278).

“Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade: O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP, rel. Ministro Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189).

E desses depoimentos restou demonstrado que os réus estavam naquele local para fazer a entrega daqueles entorpecentes a terceiros, droga que foi encontrada debaixo do banco do passageiro onde a ré Marcela se encontrava sentada, tendo ela apontado aos policiais o local.

E, como se pode observar, os depoimentos dos policiais, que são insuspeitos, não foram desmentidos por nenhum outro elemento de prova, como já ressaltado, sendo eles harmônicos entre si, de modo que não restam dúvidas de que os réus traziam consigo as drogas narradas na denúncia, as quais acabaram apreendidas.

Observo que, embora os acusados afirmem que as drogas pertencessem a um tal de “Beto”, pessoa que sequer foi por eles indicada e qualificada, não negaram o encontro das drogas dentro do veículo em que estavam.

Observo, ainda, que se as drogas pertencessem a Beto como alegado, não haveria motivos para que ele as deixasse no interior do carro dos acusados. Certamente iria levá-las consigo quando deixou o veículo. E não se diga que ele se evadiu diante da aproximação dos policiais e, por isso, não teve tempo de levá-las consigo como afirmado por Wagner, haja vista que os policiais, quando ouvidos, disseram que não avistaram ninguém sair correndo do veículo. Na verdade, avistaram Wagner parado numa esquina e resolveram abordá-lo porque demonstrou nervosismo com a aproximação dos policiais. Em nenhum momento Marcela afirmou que Beto teria saído correndo do veículo e, por isso, deixara as drogas no veículo. Ela afirmou que Wagner teria saído do carro para encontrar um amigo, de quem iria cobrar uma dívida.

Assim, não há dúvidas que eles traziam consigo e transportavam aquelas drogas que acabaram apreendidas.

E, certamente a quantidade e a forma de acondicionamento, em pequenas porções individuais prontas para comercialização, assim como a variedade, além das demais circunstâncias que envolveram suas prisões, indicam que a posse das drogas visava à comercialização e entrega a consumo de terceiros.

Dessa forma, a conduta dos réus amolda-se à figura típica definida no art. 33 “caput” da Lei nº 11343/06.

Dessa forma, passarei à dosagem de sua pena à luz do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11343/06.

Não se pode desconsiderar a quantidade de drogas encontradas em poder dos réus (99 porções individuais e 10 tubos de lança perfume) e variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína, crack e lança perfume). A cocaína é reconhecidamente

uma das variedades de drogas que causa dependência de forma mais rápida e, por conseguinte, que mais prejuízo traz à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado, de modo que se justifica a exasperação da pena base. Destaco que ambos os acusados eram tecnicamente primários, contudo o réu Wagner responde processo por idêntico delito no Estado do Mato Grosso (vide fls. 143/158 quando foi acusado de estar fazendo transporte interestadual de drogas) E, como já decidido pelo E. STF: "Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (1.240 g de crack). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. (...) É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. (...)” (HC nº. 132.600/ES Rel. Min. Dias Toffoli Informativo 828). Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime de tráfico de drogas, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa para ambos os acusados. Na segunda fase da dosimetria deve incidir a agravante da Calamidade Pública (art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, instituída pelo Decreto Estadual nº 46879/2020, publicado em 21/03/20, que tem natureza objetiva conforme recente entendimento do TJSP: "Sem razão recorrente ao postular o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal, pois é inegável a maior reprovabilidade da conduta criminosa praticada durante a pandemia de Covid-19, pois isto demonstra que o réu ignorou o isolamento social necessário para não propagação da doença. É de se considerar ainda que a sociedade como um todo mais vulnerável, sendo que aqueles que se aproveitam desta situação merecem maior reprovabilidade, já que se aproveitaram para cometer crimes, mesmo tendo consciência que muitas pessoas vêm enfrentando situações críticas financeiras" (Apelação nº. 1519958-92.2020.8.26.0228, Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 01-03-2021). Ora, certamente, estando o país em situação de pandemia na época dos fatos, onde a Saúde Pública estava seriamente comprometida, com a morte de mais de meio milhão de habitantes, a disseminação das drogas realizada pelos réus iria agravá-la ainda mais, pois o crime aqui apurado tutela justamente a Saúde Pública. Desta forma aumento suas penas em 1/6 (um sexto), resultando em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa para ambos os acusados. Incabível, no caso, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já foi reconhecido outrora pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não cabe a concessão de tal benefício àqueles que trazem consigo grande quantidade de porções de drogas, especialmente quando foram encontrados com tipos de drogas distintos (maconha, cocaína em pó e na forma de crack, além de lança perfume) e durante período de calamidade pública em razão de pandemia. Ademais não há qualquer demonstração que os réus exerçam qualquer tipo de atividade lícita, havendo evidências que faziam do tráfico seu meio de vida, estando envolvidos em atividades criminosas. Torno, assim, as penas definitivas ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição. Incabível, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade em razão da quantidade de pena aplicada e porque não se mostra suficiente e adequada para reprovar adequadamente a conduta nefasta à sociedade que exerciam. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, no regime fechado, haja vista que o crime aqui apurado é equiparado ao hediondo. Assim, somente regime mais gravoso poderá atender ao princípio da individualização da penal, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para:

a) condenar WAGNER TOBIA MASTROMORO BERTO, RG nº 36957659, pela prática do crime definido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias

multa em regime fechado;

b) condenar MARCELA FERREIRA DOS SANTOS, RG. nº 38118498, pela prática do crime definido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa em regime fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária, para cada um dos réus, na forma do art. 43 da aludida lei, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução.

Os réus foram presos em flagrante, tendo sido beneficiados com a liberdade provisória mediante a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, inciso I e IV, do CPP, cujo alvarás se encontram devidamente cumpridos às fls.63/66. Assim, concedo aos réus o benefício de recorrerem em liberdade, eis que não se vislumbram motivos no momento para decretar suas prisões preventivas.

Em que pese o pedido formulado a fls. 96/112, observando-se o quanto consta nos autos nº 14.958-50/2020 (dependente do presente), decreto a favor da União do veículo Voyage, de placas QPK-9524-Belo Horizonte, apreendido a fls. 14/15, haja vista que ficou demonstrado que, embora tivesse sido adquirido em nome da mãe do acusado Wagner, era utilizado por ele no transporte das drogas, não estando, ela, portanto, de boa fé. Aliás, os policiais afirmaram que o réu admitiu que o carro era dele, embora registrado em nome de terceiro. Assim, decreto sua perda a favor da União, na forma do art. 91, inciso II, alínea "b" do Código Penal, devendo ser revertido ao FUNAD (art. 63, § 1º da Lei nº 11.343/06), eis que proveniente e utilizado no tráfico de drogas.

Observo que já foi determinada a autorização para a incineração da droga apreendida, devendo ser mantida eventual quantidade para contraprova até o final do processo (vide fls. 58/61).

Remeta-se certidão do presente feito ao Juízo mencionado na certidão de fls. 143/158 para as providências que entender cabíveis.

Transitada em julgado a presente decisão, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, expeçam-se mandados de prisões contra eles e ofício ao SENAD informando do bem que foi declarado perdido a favor da União, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Arcarão os réus, cada qual, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, bem como das despesas processuais, caso percam a condição de beneficiários da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 01º de abril de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA